

学生A、B及びCは、身分犯の共犯に関して、次の【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から③までの( )内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

## 【会 話】

学生A. 私は、刑法第65条第1項は構成的身分の連帯作用を、同条第2項は加減的身分の個別作用を定めたものであると考えます。そして、財物を占有していない甲が、その財物を業務上占有する乙を教唆して、その財物を横領させた事案では、甲には、業務上横領罪の教唆犯が成立すると考えます。

学生B. A君は、業務上横領罪における「業務」や「占有」という点について、①(a.「業務上占有」していることが、非占有者との関係で構成的身分・b.「占有」は構成的身分であり、「業務」は加減的身分)と考えているのですね。私は、刑法第65条第1項は「共犯とする」と規定し、身分犯における共犯の成立について定めたもの、同条第2項は「通常の刑を科する」と規定し、非身分者について刑の個別作用を定めたものであると考えています。同じ事案につき、私の立場からすると、甲には、②(c.単純横領罪の教唆犯が成立し、同罪の刑が科せられる・d.業務上横領罪の教唆犯が成立し、同罪の刑が科せられる・e.業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑が科せられる)ことになります。

学生C. B君は、遺失物等横領罪の刑は「通常の刑」ではないと考えているのですね。私は、刑法第65条第1項は行為の違法性に関係する身分、すなわち違法身分の連帯作用を、同条第2項は行為者の責任に関係する身分、すなわち責任身分の個別作用を規定したものであると考えます。私の見解に立ち、占有者という身分を違法身分、業務者という身分を責任身分と考えた場合、甲には、③(f.単純横領罪の教唆犯が成立する・g.業務上横領罪の教唆犯が成立する・h.業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑が科せられる)ことになります。

1. ①a ②d ③h
2. ①a ②e ③f
3. ①a ②e ③h
4. ①b ②c ③f
5. ①b ②e ③g

No172

H30-15

## 身分犯の共犯

正解

2

正答率

75%

( ) には、順に、「①a ②e ③f」と入り、したがって、正解は肢2となる。

学生Aの立場→65条の理解について、同条1項を構成的身分の連帯作用を、同条2項を加減的身分の個別作用を、規定したものと考ええるものである。

学生Bの立場→65条の理解について、同条1項を身分犯における共犯の成立について定めたもの、同条2項を非身分者について刑の個別作用を定めたもの、と考えるものである。

学生Cの立場→65条の理解について、同条1項を違法身分の連帯作用を、同条2項を責任身分の個別作用を、規定したものと考ええるものである。

## ①について

①には、「業務」及び「占有」の身分に関する学生Aの理解が入る。

学生Aは、65条1項は構成的身分の連帯作用を、同条2項は加減的身分の個別的作用を、規定したものであると考えている。この立場によると、仮に「占有」を構成的身分、「業務」を加減的身分と解するのであれば、甲には単純横領罪の教唆犯が成立することになる。しかし、学生Aは、「業務」や「占有」の身分を有しない甲に、業務上横領罪の教唆犯を成立させている。そうすると、学生Aは、「業務」と「占有」という点について、構成的身分と解していることになる。したがって、①には「a.『業務上占有』していることが、非占有者との関係で構成的身分」が入る。

## ②について

②には、学生Bの見解に立った場合の甲の罪責が入る。

学生Bの見解は、共犯の従属性を徹底させようとする立場で、正犯と共犯は常に同一の罪が「成立する」とし、しかも1項と2項が、学生Aの立場などにおいて、1項が共犯従属性説的立場、2項が共犯独立性説的立場という、矛盾した関係に立つことになる問題を解消し、両項の関係を矛盾なく説明しようとしたものである。よって、本問の事案に関し、財物を業務上占有することの関係で65条1項が適用され、甲には業務上横領罪の教唆犯が成立することになる。また、学生Cの会話から、学生Bが遺失物等横領罪の刑は「通常の刑」ではないと考えている旨の指摘がなされており、Bの見解では、65条2項の「通常の刑」として、甲に遺失物横領等罪の刑が科されることはないということがわかる。つまり、「業務」という身分についてのみ刑の個別作用を認め、「占有」という身分には刑の個別作用を認めない。甲は「業務」という身分を有していないので、65条2項の適用により、甲には単純横領罪の刑が科せられることになる。よって、甲には、65条1項により業務上横領罪の教唆犯が成立し、65条2項の適用により単純横領罪の刑が科されることになる。したがって、②には「e. 業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑が科せられる」が入る。

## ③について

③には、学生Cの見解に立った場合の甲の罪責が入る。

会話によれば、学生Cは、「占有」という身分を違法身分、「業務」という身分を責任身分と考えている。そうすると、学生Cの見解に立つ場合、「占有」の身分については65条1項が適用されるから、連带的に作用する。他方、「業務」の身分については65条2項により、個別的に作用する。よって、甲には65条1項により単純横領罪の教唆犯が成立することになる。したがって、③には「f. 単純横領罪の教唆犯が成立する」が入る。